HABEAS CORPUS 278.903 SÃO PAULO

RELATOR	**: MIN. GILMAR MENDES**
PACTE.(S)	: IVAN FAGANELLO
IMPTE.(S)	: GUIDO PELEGRINOTTI JUNIOR
COATOR(A/S)(ES)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO: Trata-se de *habeas corpus* impetrado por Guido Pelegrinotti Junior, em favor de Ivan Faganello, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 3.101.662/SP.

Narra o impetrante, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 3 anos e 6 meses de reclusão e 20 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática dos delitos previstos nos artigos 12, 14 e 16 da Lei nº 10.826/2003, na forma do art. 70 do Código Penal.

Aponta que o Juízo de origem indeferiu a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos apenas com fundamento na reincidência do paciente.

Afirma que a reincidência, por si só, "*não representa impedimento absoluto à substituição da pena privativa de liberdade*" (eDOC 1, p. 3), consoante se extrai do art. 44, § 3º, do Código Penal.

Requer, assim, a concessão da ordem para que seja determinada a substituição da pena privativa de liberdade imposta por restritiva de direitos. Subsidiariamente, pleiteia seja determinado "[...] *novo exame da substituição penal pelo órgão jurisdicional competente, mediante análise individualizada dos requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal*" e, ainda, "*sendo afastado o fundamento legal que determinou o regime semiaberto e preenchidos os requisitos do artigo 33 do Código Penal, a fixação do regime inicial aberto*".

É o relatório.

Decido.

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em supressão de instância e ampliação da

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59E8-EDC4-699C-2FE3 e senha 0C5B-F1A0-67A6-52B1

competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019.

Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.

É este, **em parte, o caso dos autos**.

Para melhor elucidação da controvérsia, colho da sentença condenatória (informações extraídas do sítio do TJSP):

> "[...] ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para condenar o réu ivan faganello (rg: 33.988.564, filho de jair faganello e lourdes maria thomazini faganello), a uma pena de três anos e seis meses de reclusão, mais o pagamento de vinte dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como incurso nos artigos 12, "caput"; 14, "caput", e 16, "caput", todas da lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70 do código penal.
>
> **reincidente, não faz o réu jus aos benefícios previstos pelos artigos 44 e 77 do c.p**.
>
> **pelo mesmo motivo, deverá iniciar o cumprimento de sua pena em regime semiaberto**, podendo recorrer em liberdade, já que assim respondeu ao processo" (https://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?processo.codigo=GN0002P5U0000&processo.foro=451&processo.numero=1501890-14.2021.8.26.0599).

Ainda, transcrevo a fundamentação do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem (eDOC 11, p. 9-10):

> "No mais, **o regime prisional era mesmo de ser fixado no**

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59E8-EDC4-699C-2FE3 e senha 0C5B-F1A0-67A6-52B1

> **semiaberto, novamente, por conta da reincidência do acusado, nos termos do disposto no art. 33, §2º do CP**. A propósito, a Súmula 269 do eg. STJ estabelece que "*É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais*". No mesmo teor, o recente julgado do eg. STJ: AgRg no AREsp 2722168 SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJEN 09/12/2024.
>
> [...]
>
> Outrossim, **incabível a substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, pois não preenchido o requisito previsto no art. 44, inc. II do CP**".

Nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal, o condenado **não reincidente**, nos casos em que a pena fixada seja igual ou inferior a 4 anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Ocorre que, na espécie, **o paciente é reincidente,** conforme ponderado pelas instâncias anteriores. Nessa toada, apesar da não verificação de demais circunstâncias desfavoráveis, **o entendimento não se revela ilegal, tampouco contrário à jurisprudência desta Corte**.

No que se refere à substituição por restritivas de direitos, por outro lado, o art. 44 do Código Penal estabelece:

> Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
>
> I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;
>
> II – **o réu não for reincidente em crime doloso**;
>
> III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59E8-EDC4-699C-2FE3 e senha 0C5B-F1A0-67A6-52B1

> personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

De fato, o art. 44 do CP prevê expressamente, como condição para a pretendida substituição, que o réu não seja reincidente. O parágrafo 3º do mesmo dispositivo, contudo, autoriza a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ao reincidente não específico, desde que a medida seja socialmente recomendável.

Nesse sentido, a Segunda Turma desta Corte, nos autos do HC 169.956, de minha relatoria, ao reproduzir texto legal, assentou que **o reincidente não específico "*tem direito à substituição da pena*, *desde que a medida seja socialmente recomendável*"**.

A reincidência, portanto, por si só, não é obstáculo à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Na espécie, o paciente foi condenado pelos delitos descritos nos artigos 12, 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento, à pena que, ao final, ficou fixada no mínimo legal, em razão da compensação entre a confissão e a reincidência. Ainda, não houve qualquer agravamento na primeira fase, a demonstrar a presença de circunstâncias judiciais positivas.

As instâncias de origem, entretanto, negaram ao paciente a referida substituição apenas em razão da reincidência, a evidenciar ausência de fundamentação no trecho da decisão que a indeferiu, razão por que a concessão da ordem, quanto a este aspecto, é medida imperiosa.

Ante o exposto, **nego seguimento** ao *habeas corpus* (art. 21, § 1º, RISTF), mas **concedo parcialmente a ordem, de ofício,** para **determinar ao Juízo de origem que avalie, fundamentadamente, a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos**.

Comunique-se imediatamente para fins de cumprimento da ordem.

Publique-se.

Brasília, 29 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59E8-EDC4-699C-2FE3 e senha 0C5B-F1A0-67A6-52B1

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001 de 24/08/2001. O documento pode ser acessado pelo endereço http://www.stf.jus.br/portal/autenticacao/autenticarDocumento.asp sob o código 59E8-EDC4-699C-2FE3 e senha 0C5B-F1A0-67A6-52B1